

1501141-16.2019.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Marcondes da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

RAFAEL MARCONDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 273, § 1º-B, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501141-16.2019.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501141-16.2019.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Marcondes da Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

RAFAEL MARCONDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 273, § 1º-B,

incisos V e VI, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 220/222) e o aditamento (fls. 438/440):

a) no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 06h00, na Rua Aleixo Balbino Neves, nº 145, Conjunto Habitacional Ana Jacinta, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, guardou, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de maconha, uma pesando 24,4g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas) e outra pesando 29,9g (vinte e nove gramas e nove decigramas), tratando-se de substância que contém Tetrahydrocannabinol (THC), o qual está relacionado na lista F2 da Portaria nº 344/98 da ANVISA; e

b) entre 10 de julho de 2019 e 06 de dezembro de 2019, importou, vendeu e manteve em depósito, para venda, distribuição e entrega ao consumo de terceiros, citrato de sildenafil, produto de procedência ignorada, adquirido de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu guardava as porções de maconha em sua residência. Além disso, importou citrato de sildenafil de procedência ignorada, adquirido de fornecedor sem licença da autoridade sanitária competente, por meio do site Mercado Livre, e manteve a substância em depósito, com o intuito de posteriormente entregá-la ao consumo de terceiros.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da Operação Xequê Mate, policiais civis compareceram à moradia do denunciado e lá encontraram as substâncias acima descritas.

Além da maconha e do citrato de sildenafil, acharam R\$ 80,00, em dinheiro, uma balança de precisão, um rolo de filme plástico e mensagens alusivas ao comércio de substâncias ilícitas.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam o propósito de fornecimento da droga a terceiros.

A denúncia (fls. 220/222) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/215) e foi recebida em 17 de dezembro de 2019 (fls. 227).

Citado (fls. 239), o réu, assistido por Defensor constituído (fls. 160), apresentou resposta à acusação (fls. 276/278).

Inexistindo questão preliminar a analisar e ausente causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 276/278).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 411/412).

O Ministério Público aditou a denúncia (fls. 438/440).

Intimado para se manifestar sobre o aditamento (fls. 443), o Defensor permaneceu inerte (fls. 444).

Recebido o aditamento à denúncia (fls. 445), o Promotor de Justiça e o Defensor, intimados (fls. 446/449), não manifestaram interesse na reinquirição de testemunhas (fls. 450).

O réu foi novamente interrogado, com registro em gravação audiovisual (fls. 469/470).

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 475/487).

O Defensor, nos seus memoriais, aduziu a ilegalidade do relatório de investigação de fls. 38/46 e do laudo de exame pericial de fls. 244/259. No mérito, requereu a absolvição, alegando a atipicidade da conduta consistente em possuir citrato de sildenafil. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta consistente em possuir porções de maconha para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea; pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; pela substituição desta por restritiva de direitos; e pela restituição dos bens apreendidos (fls. 499/529).

Foi revogada a prisão domiciliar do acusado (fls. 532).

Juntaram-se documentos (fls. 535/539 e 560/3867), sobre os quais se manifestaram o Ministério Público (fls. 3870) e o Defensor (fls. 3877 e 3880).

É o relatório.

DECIDO.

I. Arguições preliminares.

A realização de buscas na residência do réu e a submissão do celular dele à perícia foram autorizadas pela decisão de fls. 535/539, proferida na autuação nº 1513067-06.2019.8.26.0482.

O laudo de fls. 104/206, concernente à investigação sobre fato praticado por Victor Eduardo do Nascimento Caires, no dia 07/06/2019 (fls. 104), demonstra que um indivíduo identificado como Rafael, usuário da linha telefônica nº +55 18 08118-6663, negociou a compra de drogas de Victor, no dia 06/06/2019 (fls. 176).

O relatório de fls. 208/215 informa que a operadora de telefonia, no feito originário, atribuiu a titularidade da linha telefônica nº +55 18 08118-6663 a Rafael Marcondes da Silva (fls. 212).

O laudo já referido (fls. 104/206) também indica que indivíduo identificado como Ralf, provavelmente Rafael (fls. 127), guardava drogas para Victor (fls. 127/129).

O acesso a dados do celular era necessário, pois o laudo de fls. 104/206 revela que Victor e Rafael usavam aquele instrumento para se comunicar entre si.

Como o acesso aos dados do celular do acusado foi autorizado (fls. 535/539), fica afastada a alegação preliminar de nulidade do relatório de fls. 38/46 e do laudo de fls. 244/259, por ausência de decisão judicial.

Não se vislumbra violação à cadeia de custódia do aparelho celular apreendido.

O celular foi adequadamente coletado (fls. 09/13 e 15/16) e acondicionado em invólucro individual fechado pelo lacre nº 8795 (fls. 96), que foi preservado até a realização do exame pericial (fls. 245).

Obedeceu-se, portanto, aos procedimentos previstos no artigo 158-B do Código de Processo Penal.

Apesar disso, não se utilizará o relatório de investigação de fls. 38/44 como fundamento para esta decisão, pois as trocas de mensagens referidas naquele documento não foram descritas no laudo de exame do aparelho celular (fls. 244/259), nem estão nos relatórios de extração de dados de fls. 560/894, 895/3865 e 3866/3865.

Sendo assim, ficam afastadas as aduções preliminares.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

II. Análise do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelos autos de prisão em flagrante delito (fls. 03/08) e de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 19/21), pelos laudos periciais de fls. 104/206, 244/259, 281/284, 288/290 e 291/295, e pelos relatos orais, colhidos sob o contraditório. Os relatos orais também revelaram a autoria das infrações penais.

Vejamos o conjunto probatório.

II.I. Sobre a posse dos objetos apreendidos.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 19/21) demonstra a natureza entorpecente da substância descrita como maconha no auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), haja vista a presença de Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Os laudos de fls. 288/190 e 291/295 evidenciam que os comprimidos revestidos apreendidos, acondicionados em caixas amarelas, contêm citrato de sildenafil.

Não há dúvidas de que as porções de maconha e os comprimidos de citrato de sildenafil estavam sob a posse do acusado, pois as declarações dele e das testemunhas policiais civis convergiram nesse sentido.

A testemunha André Luiz Zanandrea (fls. 411/412), policial civil, informou que compareceu à residência do réu para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Quando ingressou no quarto do denunciado, deparou-se com ele deitado, mas acordado. Ao lado dele, sobre a cama, havia uma porção de 25g de maconha, envolta em plástico filme. Sobre a cama, encontraram ainda um rolo de plástico filme e um pote branco com a inscrição teste e um creme branco em seu interior.

Embaixo do corpo de acusado, havia uma balança de precisão. Sob a cama, localizaram 13 (treze) caixas de citrato de sildenafil. Além desses objetos, também apreenderam o telefone celular dele e R\$ 80,00 (oitenta reais), que ele tinha na

carteira. Imediatamente, Rafael alegou que a droga se destinava ao consumo pessoal. Logo depois, com o auxílio de cão farejador, encontraram uma porção de 30g de maconha no carro do denunciado, sob a capa plástica do freio de mão. Segundo os pais de Rafael, o veículo pertencia a ele, mas era dirigido pelo irmão ou amigos do réu. Informou que o acusado usa uma cadeira de rodas para se locomover.

A testemunha Diego Rassaneis dos Santos (fls. 411/412), também policial civil, informou que participou da diligência na moradia do réu, mas permaneceu na contenção. Afirmou que o odor de maconha se estendia por toda a casa e uma porção daquela droga foi encontrada no quarto do denunciado.

Nas ocasiões em que foi interrogado (fls. 411/412 e 469/470), o réu declarou que as porções de maconha e os comprimidos de citrato de sildenafila apreendidos estavam sob a sua posse, em sua residência.

A convergência entre os relatos orais evidencia que os bens descritos no auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) foram encontrados na residência do réu e estavam sob a posse dele.

Resta verificar qual seria a destinação da substância entorpecente e do medicamento.

II.II. Destinação das porções de maconha e classificação jurídica da conduta.

Interrogado (fls. 411/412 e 469/470), o réu asseverou que a maconha e os comprimidos de citrato de sildenafila se destinavam ao seu próprio consumo. Disse que sofreu acidente motociclistico há aproximadamente oito anos, o que acarretou prejuízo à sua função sexual. Contudo, nunca buscara orientação médica para tratar a disfunção, pois depende de familiares para se locomover e considerava constrangedor pedir-lhes ajuda para essa finalidade. Para normalizar sua função sexual, fazia uso de citrato de sildenafila. Aproximadamente cinco meses antes do fato, comprara doze caixas de citrato de sildenafila, para o próprio uso. Disse haver comprado grande quantidade, porque o preço era muito vantajoso. Alguns dias antes da prisão, comprara aproximadamente 55g de maconha, dividira a droga em duas porções, escondera uma delas no carro e guardara a outra em seu quarto. Disse que escondera uma porção no carro para evitar que seus familiares ou animais a encontrassem e ter melhor controle do quanto poderia consumir ao longo do mês. Na data do fato, estava consumindo um cigarro de maconha, quando os policiais chegaram. Negou que tenha negociado a venda de drogas por meio de telefone celular. Disse que comprara o carro financiado em parcelas de R\$ 612,00 (seiscentos e doze reais). Informou que é aposentado por invalidez e tem renda mensal de um salário-mínimo.

Renato Nunes da Silva (fls. 411/412), padrasto do réu, declarou que o enteado é usuário de maconha há muitos anos e costuma consumir a droga na residência da família. Afirmou que ele é aposentado por invalidez, tem renda mensal de um salário-mínimo, comprou um carro aproximadamente um ano antes da prisão em flagrante delito e contribuía mensalmente com o orçamento da casa, com R\$ 300,00 ou R\$ 350,00.

Inobstante a versão apresentada pelo réu, os laudos de exames de telefones celulares (fls. 104/206 e 244/259) demonstram que ele praticava o tráfico de drogas, guardando substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros. O laudo de fls. 244/259 resulta do exame pericial a que foi submetido o telefone celular do acusado, Rafael, apreendido no dia 06/12/2019 (fls. 15/16).

Segundo o laudo de fls. 244/259, havia no celular de Rafael a reprodução de tela de uma troca de mensagens por meio do aplicativo Whatsapp, com contato identificado como Higor Padilha (fls. 251).

Naquela troca de mensagens, o denunciado afirmou que guardara 400g ou 1kg de bucha quando lebrão foi preso. Leia-se (fls. 251):

Rafael: Fi as fita das bucha vc falo pra ele q quando o lebrão foi preso so tinha 400g aqui?

Pq foi assim n dog quando ele rodo tinha 1kg vc lembra ainda vc pediu pra mim pesa pra devolver pro manno

Ai dps vc pego 2 q deu 500g pacotes q era da parte do lebrão e fico 2 aq ai dps desses 2 fico 400 da ultima

Lebrão, referido por Rafael, é alcunha de Victor Eduardo do Nascimento Cares,

conforme se verifica no laudo de fls. 104/206.

O laudo de fls. 104/206 é resultado do exame pericial no celular de Victor Eduardo do Nascimento Cares, apreendido em 07/06/2019, no âmbito de outra investigação, conforme descrição de fls. 104 e relatório de fls. 208/215. Aquele laudo (fls. 104/206) reproduz mensagens trocadas entre Victor Cares e diversos interlocutores. Em troca de mensagens com o usuário da linha telefônica +55 18 99719-8410, o interlocutor trata Victor Cares para a alcunha Lebrão (fls. 141):

Interlocutor:Fala pra vc agora to bem tranquilo Almoçando. Fica tranquilo. Lebrao, não vou me indispor agora não, a hora que nois se tromba nois resolve po.

(...)

Não to ameaçando não lebrao

Na troca de mensagens com indivíduo identificado como Victor Vasc, o interlocutor trata Victor Cares pela alcunha Lebres (fls. 152):

Victor Vasc:salve lebres

Victor Cares:Salve

Portanto, é certo que Victor Cares é conhecido pelas alcunhas Lebrão, Lebre ou Lebres.

Por meio de mensagens trocadas no dia 06/06/2019, Victor Cares ajustou a entrega de drogas ao denunciado Rafael, usuário da linha telefônica nº +55 18 08118-6663, nos seguintes termos (fls. 176):

Victor Cares:Que horas vc tava pensando em pegar o negócio

Rafael:Agora pode ser

Victor Cares:O gu falou pra dar um salve

Mano, eu tenho que ir no moco, não fico com nada em casa

(...)

Vc tem pressa pra fumar? Se for eu tenho aqui e te arrumo enquanto isso

O relatório de fls. 208/215 informa que a operadora de telefonia, no feito originário, atribuiu a titularidade da linha telefônica nº +55 18 08118-6663 a Rafael Marcondes da Silva (fls. 212).

A troca de mensagens de fls. 176 demonstra o vínculo entre Victor Cares e o acusado Rafael.

Inobstante a alusão ao interesse de Rafael em fumar a droga (fls. 176), a troca de mensagens de fls. 251 demonstra que o denunciado, Rafael, guardava grandes quantidades de maconha para Lebrão (Victor Cares) e terceiro.

Outra troca de mensagens corrobora a informação de que o denunciado Rafael guardava drogas para terceiros.

O laudo já referido (fls. 104/206) indica que indivíduo identificado como Ralf negociou entrega de drogas a Victor, nos dias 06 e 07 de junho de 2019 (fls. 127/129).

Note-se que, segundo o subscritor do laudo (fls. 104/206), o indivíduo identificado como Ralf é provavelmente o contato Rafael conversa na página 72 (fls. 127). A página 72, referida pelo experto, está às fls. 176 da autuação digital.

Consoante se expôs anteriormente, o contato Rafael (fls. 176) é o acusado Rafael Marcondes da Silva.

Não há dúvidas de que Ralf (fls. 127/129) é codinome atribuído ao denunciado Rafael Marcondes da Silva.

Conforme se verifica pela imagem de fls. 127, Ralf usava um retrato fotográfico de Rafael Marcondes da Silva como imagem de identificação pessoal no Whatsapp.

Note-se que o retrato fotográfico de fls.127 coincide com a imagem do tipo miniatura atrelada à mensagem enviada de áudio de fls. 253, contida no celular de Rafael.

Além disso, Ralf e Victor Cares conversaram sobre a guarda de 990g de drogas pelo primeiro (fls. 129).

A menção à posse de 990g por Ralf/Rafael é compatível com troca de mensagens de fls. 251, em meio à qual Rafael declara que quando ele (Lebrão) rodo tinha 1kg.

Em meio às mensagens, Victor Cares também determinou que Ralf/Rafael não deixasse Padilha mexer na substância entorpecente (fls. 129).

A orientação relacionada a Padilha compatibiliza-se com a troca de mensagens de fls. 251, entre Rafael e contato identificado como Higor Padilha.

Leia-se a troca de mensagens entre Ralf/Rafael e Victor Cares (fls. 128/129):

Victor Cares:Mano tem como pegar um pouco aí

Tô sem

(...)

Um mano vai pegar um voo

(...)

Rafael:Dmr vem antes das 5

(...)

Slv ae abri td separei as maior pro mano

Sobro 180 no pacote

Victor Cares:Fmza irmão, só agradece

Hora que vc falar eu já colo

Rafael:pode vim

(...)

Victor Cares:Irmão

Não e pra deixar ele mexer nos baby mais não fmza, o padilha

Rafael:Fala mano

Victor Cares:O mano aqui falou que ele disse que foi ai e tals

Nos bang**

Rafael:Nem veio

Ta aq

Tem 990g aq dele

Victor Cares:(áudio não reproduzido)

Rafael:Slc Mais e isso então pra vc sabe tem 990 dmr

A utilização de retrato do acusado (fls. 127) e a alusão a fatos também tratados às fls. 251, como a quantidade de maconha e a ciência de Padilha sobre o fato, evidenciam que Ralf é codinome de Rafael Marcondes da Silva e que as mensagens de fls. 128/129 foram trocadas entre ele e Victor Cares.

As trocas de mensagens de fls. 127/129, 176 e 251 não deixam dúvidas de que o denunciado Rafael guardava substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros.

As evidências de que o acusado guardava drogas destinadas ao fornecimento a terceiros (fls. 127/129, 176 e 251) revelam que as porções de maconha apreendidas no dia 06/12/2019 teriam a mesma destinação.

Não é minimamente factível a adução de que escondia parte da droga no carro para evitar que familiares a encontrassem, pois o padrasto do acusado, Renato Nunes da Silva, informou que o enteado costumava consumir maconha na residência da família. Renato Nunes da Silva (fls. 411/412), padrasto do réu, declarou que o enteado é paraplégico, em decorrência de acidente motociclístico sofrido há oito ou nove anos. Afirmou que Rafael é aposentado por invalidez, tem renda mensal de um salário-mínimo e contribui mensalmente com R\$ 300,00 ou R\$ 350,00, para custear as despesas da casa. Disse que o denunciado costuma consumir maconha na residência da família, não tem namorada, sai pouco de casa e não costuma ser visitado por mulheres ou parceiros, à exceção de um amigo. Declarou que seu enteado comprou um automóvel há aproximadamente um ano, mas o veículo é dirigido por colegas e pelo irmão dele.

Como o acusado disse ter rendimento mensal de um salário-mínimo, despendia R\$ 612,00 com o pagamento de parcelas do veículo (fls. 423/429) e contribuía com R\$ 300,00 para pagar as despesas da família, não é crível que dispusesse de fundos para comprar grandes quantidades de maconha, de uma única vez, para o próprio consumo.

Somados, os elementos acima expostos demonstram que as porções de maconha apreendidas se destinavam ao fornecimento a terceiros.

Ao guardar substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o denunciado materializou conduta abstratamente prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Não se aplica a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº

11.343/06.

As mensagens de fls. 127/129 e 176 foram trocadas em 06 e 07 junho de 2019. Naquelas datas, o denunciado já guardava substâncias entorpecentes para terceiros. A apreensão de drogas na residência e no automóvel do réu ocorreu em dezembro de 2009.

O intervalo entre as ações evidencia que Rafael se dedicava à atividade criminosa, circunstância que obsta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

II.III. Destinação dos comprimidos de citrato de sildenafil e classificação jurídica da conduta.

Conforme se expôs anteriormente, o réu, nos interrogatórios (fls. 411/412 e 469/470) declarou que os comprimidos de citrato de sildenafil se destinavam ao seu próprio uso. Afirmou que padece de disfunção erétil desde o acidente motociclistico, que lhe causou deficiência física. Como depende de familiares para se locomover e não desejava que soubessem de sua disfunção, nunca procurou orientação médica para tratá-la, nem para obter receita para comprar o medicamento. Aproximadamente cinco meses antes do fato, comprou doze caixas do medicamento para uso pessoal, pelo site Mercado Livre. Disse que comprou grande quantidade, porque o preço lhe era vantajoso.

Os documentos de fls. 430/431 não descrevem citrato de sildenafil, mas um produto qualificado pelo vendedor como Forte Homem Total 48 Unidades 12 Cxs Total Sabor v i a g r o n n n.

Ainda que se admitam os documentos de fls. 430/431 como prova de que os comprimidos de citrato de sildenafil foram comprados através do Mercado Livre, a grande quantidade revela que o réu pretendia comercializá-los.

Não parece razoável que Rafael comprasse tamanha quantidade, de uma vez, para o próprio uso, pois todas estavam lacradas e, segundo a versão apresentada pelo réu, permaneceram meses sem uso.

Além disso, ao menos uma das caixas de comprimidos tinha origem diversa da alegada pelo réu, pois ele teria comprado apenas doze caixas por meio do Mercado Livre, mas tinha treze caixas em casa (fls. 15/16).

Acrescente-se que as caixas de comprimidos eram de dois lotes distintos, conforme demonstram os laudos de fls. 288/290 e 291/295.

Dez das caixas eram do lote B18J2492 e três, do lote B18F2197 (fls. 292).

Impossível supor que, ao comprar doze caixas do mesmo medicamento, recebesse duas de lote coincidente com o de comprimidos que já tinha em casa.

A quantidade de caixas e comprimidos apreendidos revela que o denunciado pretendia comercializá-los.

Os comprimidos apreendidos são medicamentos (art. 273, caput, CP), conforme se verifica pela inscrição Medicamento Genérico contida em todas as caixas (fls. 288/295).

Consoante se expôs anteriormente, as circunstâncias do fato evidenciam que os medicamentos se destinavam à venda (art. 273, § 1º, CP).

Doze das caixas, segundo a argumentação do réu, foram compradas de estabelecimento sem licença de autoridade sanitária, que dissimulava a venda do produto com codinome (fls. 430/431) (art. 273, § 1º-B, VI, CP).

A procedência de uma das caixas não foi esclarecida. Portanto, trata-se de produto de procedência ignorada (art. 273, § 1º-B, V, CP).

Ao ter em depósito produtos medicinais destinados à venda, parte de procedência ignorada e parte adquiridos de estabelecimento sem licença para comercializá-los, o denunciado realizou condutas abstratamente previstas no artigo 273, §§ 1º e 1º-B, incisos V e VI, do Código Penal.

A despeito da capitulação jurídica do fato, aplicam-se as penas cominadas para o tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. Ao julgar a arguição de inconstitucionalidade formulada no HC n. 239.363/PR, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário da norma do artigo 273, § 1º-B, inciso V do Código Penal. 2. Em atenção à referida decisão, as Turmas que

compõem a 3ª Seção deste Sodalício passaram a determinar a aplicação do preceito secundário do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aos casos em que o acusado é condenado pelo crime previsto no artigo 273, § 1º-B, do Código Penal. Precedentes. (...) (STJ; Quinta Turma; HC 377422/PR; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 07.03.2017). (...) Ordem concedida de ofício para aplicar ao artigo 273, § 1º-B, incisos III e V, do Código Penal o preceito secundário do artigo 33 da Lei 11.343/2006, fixando-se a pena da paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estendendo-se os efeitos desta decisão ao corréu Márcio Gomes Vicente. (...) (STJ; Quinta Turma; HC 366065/DF; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 11.10.2016).

Incabível, porém, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, por ausência de previsão legal de extensão da benesse à infração penal em comento. Nesse sentido:

(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível, por ausência de previsão legal, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 nos crimes previstos no art. 273, § 1º-B, do CP, mesmo nas hipóteses em que se tenha utilizado o preceito secundário do crime de tráfico de drogas. (...) (STJ; Terceira Seção; RvCr 3064/PR; Relator: Ministro Nefi Cordeiro; j. 22.02.2017).

III. Concurso de crimes.

Há concurso material entre as infrações penais (art. 69, CP), pois foram praticadas por meio de ações independentes, com desígnios autônomos.

Demonstradas, pois, a materialidade delitativa e a autoria da conduta e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da sanção, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 273, §§ 1º e 1º-B, incisos V e VI, do Código Penal, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal).

Passo a dosar a pena.

IV. Dosagem das penas.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao denunciado.

Por conseguinte, fixam-se as penas-base nos patamares mínimos, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime previsto no artigo 273, §§ 1º e 1º-B, incisos V e VI, do Código Penal.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixa-se o valor unitário da pena de multa no mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado.

Na segunda etapa da dosagem da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Em que pese a argumentação do Defensor, as declarações do acusado não constituem confissão espontânea, pois ele negou a intenção de fornecer os produtos ilícitos a terceiros.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno, novamente, a inaplicabilidade da diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o acusado se dedicava ao tráfico de drogas.

Somadas, na forma dos artigos 69 e 72 do Código Penal, as sanções totalizam 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o disposto no § 2º do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal.

Por não preencher requisito objetivo (quantum da sanção), o acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem à suspensão condicional da sanção (art. 44 e 77, CP).

V. Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar RAFAEL MARCONDES DA SILVA, nascido aos 25/07/1989, natural de Presidente

Prudente/SP, filho de Márcia Cristina Marcondes Silva e de Daniel João da Silva, inscrito no Registro Geral nº 44.606.326-5 SSP/SP e no CPF nº 393.266.068-48 (fls. 36), pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 273, §§ 1º e 1º-B, incisos V e VI, do Código Penal, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), a cumprir pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 1.000 (mil) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade e a origem espúria das caixas de medicamento, autorizo a imediata destruição da droga e dos medicamentos que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido é produto do tráfico de drogas; e o celular foi usado para a prática do crime. Por tal motivo, declaro o perdimento do montante e do celular em favor da União (art. 63, Lei nº 11.343/06).

Em que pese uma das porções de maconha haver sido encontrada sob a capa plástica do freio de mão do veículo apreendido, não há notícia de preparação do veículo Citroen C3, placas FEC-7699 (fls. 15/16) para servir ao tráfico. Sendo assim, autorizo sua restituição do proprietário, após o trânsito em julgado.

Os demais objetos apreendidos, consistentes em um pote em forma de estrela, uma balança, um pacote de fumo e um rolo de papel filme (fls. 15/16), são inservíveis. Assim sendo, autorizo sua imediata destruição.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 160); e há mídias arquivadas em cartório (fls. 558).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão de bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Presidente Prudente, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA